

1528377-67.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... indiciários quanto ao delito de associação para o tráfico em relação ao réu CARLOS MAGNO foram confirmados, revelando a indubitável autoria delitiva do referido acusado, o mesmo não se pode afirmar sobre o tráfico de drogas em relação aos réus e sobre a associação para o tráfico no que tange ao réu GILBERTH.

Vejamos.

A testemunha Andre Araujo de Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1528377-67.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528377-67.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316489/2021 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 21509701 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 233/21/100 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2316489 - DEL.SEC.1ª CENTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILBERTH JOSÉ DA SILVA MENEZES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

VISTOS.

GILBERTH JOSÉ DA SILVA MENEZES e CARLOS MAGNO DURANS RODRIGUES, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incurso no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 70, "caput", do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 21 de novembro de 2021, às 21h, no interior da empresa Edu Turismo, situada na Rua General Rondon, n.º 107, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tinham em depósito e guardavam, para fins de comércio, 27 tijolos de tetrahidrocannabinol - maconha, com peso líquido de 28,6kg, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação de acostados nos autos, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias supra descritas, GILBERTH JOSÉ DA SILVA MENEZES e CARLOS MAGNO DURANS RODRIGUES associaram-se para o fim de praticar crime de tráfico de drogas.

Segundo o apurado, os denunciados tinham em depósito e guardavam os tijolos de "maconha" para comercialização.

Após reiteradas informações noticiando que no local dos fatos havia armazenamento de substâncias entorpecentes que eram enviadas para fora do estado de São Paulo como "encomendas", policiais civis passaram a efetuar diligências.

Na data dos fatos, os policiais resolveram averiguar um ônibus que estava estacionado em frente à empresa "Edu Turismo", onde nada de ilícito foi encontrado.

Após busca minuciosa no citado ônibus, nada de ilícito fora encontrado. Porém, os policiais verificaram uma porta aberta do estabelecimento e visualizaram inúmeras caixas no interior do imóvel.

Nesse instante, os policiais ingressaram no imóvel após o denunciado CARLOS MAGNO abrir a porta do local e autorizar a entrada.

Ao adentrarem no imóvel, os policiais sentiram um forte odor da substância conhecida como maconha.

Indagado se havia entorpecentes no local, CARLOS ficou extremamente nervoso e, ao apresentar seu documento pessoal e seu aparelho de celular, deu um forte empurrão em um dos policiais, evadindo-se na sequência.

Diante das circunstâncias, os policiais solicitaram às testemunhas que estavam no local para que acompanhassem a revista no imóvel.

Assim, ao abrir a caixa de onde advinha o odor, foram localizados 27 tijolos de substância maconha.

Nas demais caixas, nada de ilícito fora encontrado.

Ato contínuo, os policiais encontraram nos fundos do imóvel, em um banheiro, o denunciado GILBERTH JOSE DA SILVA MENEZES, que estava escondido, agachado atrás do vaso sanitário, também exalando forte odor da substância.

Indagado sobre os entorpecentes encontrados, GILBERTH alegou que ele e CARLOS MAGNO recebiam a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) da pessoa de Eduardo para embalar as drogas, bem como que CARLOS MAGNO recebia mais R\$ 2.000,00 (dois mil reais) reais para embarcar junto com as substâncias nos ônibus e entregá-las aos seus destinos.

No local, também foi apreendida uma balança de precisão grande, de acordo com auto de exibição e apreensão de fls. 13/14.

Diante disso, os policiais prenderam GILBERTH em flagrante e o conduziram à sede policial.

Em interrogatório a fl. 17, ele silenciou.

O denunciado CARLOS MAGNO não foi localizado pelos policiais. Os réus foram notificados (fls. 130 e 153) e apresentaram defesa preliminar (fls. 156/157 e 171/184). A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2022 (fls. 187/10). Os réus foram citados pessoalmente e mantiveram contato reservado com os seus respectivos Defensores (fls. 257 e 258).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas. Após, deu-se os interrogatórios dos réus. Nada foi requerido pelas partes.

As partes debateram a causa. O Ministério Público requereu a condenação em razão das provas amealhadas. A Defesa do réu CARLOS MAGNO postulou. A Defesa do réu GILBERTH pleiteou

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/10), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de constatação (fls. 30/32) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 261/263). Os peritos subscritores do laudo atestaram que as substâncias apreendidas eram, de fato, TETRAHIDROCANNABINOL (THC - "maconha").

A autoria, com base nos elementos investigativos colhidos na fase inquisitiva, apontava para os réus em relação a ambos os delitos imputados.

A testemunha Andre Araujo de Andrade, policial civil ouvido na fase extrajudicial, declarou que após reiteradas informações de que, naquela localidade, drogas eram enviadas para fora do estado de São Paulo como "encomendas", o depoente se suas colegas policiais civis passaram a diligenciar no local dos fatos, sendo que na data dos fatos, por volta das 21 horas (do dia 21/11/2021), resolveram por bem checar o que seria carregado no ônibus que estava estacionado em frente à empresa Edu Turismo. No local, após efetuarem a varredura minuciosa no referido ônibus, nada de ilícito fora encontrado, momento em que perceberam que a porta principal que dá acesso ao imóvel dentro do referido estabelecimento estava aberta, e conseguiram visualizar inúmeras caixas. Neste momento, um indivíduo abriu o restante daquela porta já entreaberta, sendo identificado como a pessoa de CARLOS MAGNO DURANS RODRIGUES, o qual tomou conhecimento da abordagem. Neste momento, foi possível sentir um forte odor de substâncias conhecida como maconha advindo da pessoa de CARLOS e também das caixas de encomendas que estavam neste local. Indagado se havia entorpecentes no local, o mesmo ficou extremamente nervoso, motivo pelo qual os policiais solicitaram a apresentação de seu documento pessoal e seu aparelho de celular, momento em que ao entregar tais objetos, deu um forte empurrão no policial depoente, posteriormente se evadindo do local correndo, não sendo possível alcançá-lo. Dadas as circunstâncias, os policiais solicitaram às testemunhas que estavam no local para que acompanhassem o depoente na revista no local, sendo que através do odor ora mencionado, foi possível identificar de qual caixa advinha tal odor de maconha, sendo que ao abri-la, foram localizados 27 tijolos de substância maconha, sendo todas as demais caixas abertas e nada de ilícito fora encontrado. Ao adentrar o imóvel para término da varredura, encontraram nos fundos, em um banheiro, a pessoa de GILBERTH JOSE DA SILVA MENEZES, o qual estava escondido agachado atrás do vaso sanitário, inclusive exalando forte odor de maconha. Indagado sobre tais substâncias encontradas, GILBERTH alegou que

ele e CARLOS MAGNO recebiam a quantia de R\$ 500 reais da pessoa de Eduardo para embalar tais entorpecentes e que CARLOS MAGNO recebia mais R\$ 2.000,00 reais para embarcar junto com as substâncias nos ônibus e entregar aos seus destinos (fls. 13).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Genildo da Fonseca Nascimento Filho, seu colega de ofício (fls. 14).

A testemunha Marcos Rogerio da Conceição, ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos estava descansando dentro do veículo Busscar Hi Scania 124, de placas BSF-9295, momento em que ouviu um indivíduo entrando no ônibus dizendo "Polícia!" sic, sendo que o declarante desceu do ônibus obedecendo a ordem do policial que estava em diligência. O declarante informou que após varredura no referido ônibus, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, os policiais, ao efetuarem a verificação do imóvel que abriga a transportadora Edu Turismo, que estava com a porta principal semiaberta, viram o momento em que um indivíduo saiu de dentro do referido imóvel (CARLOS MAGNO). Disse que os policiais encontraram diversos tijolos de substância conhecida como maconha em uma caixa de papelão embalada com fita adesiva amarela aberta na sua presença. A referida caixa, aberta pelos policiais, já exalava forte cheiro de maconha e nas demais caixas que foram abertas nada de ilícito foi localizado. Questionado acerca daquelas substâncias, o declarante informou não saber de quem são tais substâncias. Ademais, o declarante informou que o indivíduo o qual estava dentro do imóvel (CARLOS MAGNO) se evadiu do local correndo no momento em que os policiais estavam efetuando a varredura dentro do imóvel, não sendo mais localizado pelos policiais. Por fim, o declarante informou que também estava no local com seu colega VALDEMIR aguardando por um carreto onde o declarante iria levar passageiros e encomendas para a região de São Luís - MA e que seu contato era a pessoa de Eduardo (fls. 15).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Valdemir Soares Correa (fls. 16).

Interrogado em solo policial, o réu GILBERTH permaneceu em silêncio (fls. 21).

O réu CARLOS MAGNO não foi interrogado em solo policial, pois se evadiu do local correndo, sendo preso posteriormente.

E, sob o crivo do contraditório, se os elementos indiciários quanto ao delito de associação para o tráfico em relação ao réu CARLOS MAGNO foram confirmados, revelando a indubitável autoria delitiva do referido acusado, o mesmo não se pode afirmar sobre o tráfico de drogas em relação aos réus e sobre a associação para o tráfico no que tange ao réu GILBERTH.

Vejamos.

A testemunha Andre Araujo de Andrade declarou que no dia dos fatos, por volta das 11hs, tinham denúncia que drogas eram enviadas para fora de São Paulo e se dirigiram ao local, onde encontraram um ônibus de turismo, onde havia duas testemunhas. Realizaram abordagem nelas e fizeram varredura no ônibus e nada de ilícito foi encontrado. Indagaram às testemunhas, ao que elas disseram que iriam fazer uma entrega. Ao lado de fora de ônibus, que estava estacionado em frente à agência "Edu Turismo", o réu CARLOS MAGNO abriu a porta do local. Ele demonstrou nervosismo, solicitou o documento dele, momento em que o réu empurrou o depoente e saiu correndo. Disse que voltou ao local para auxiliar seu colega Genildo e fizeram varredura no local, onde encontraram em uma caixa diversos tijolos de maconha. Aduziu que continuando a varredura pelo local, encontraram o corréu GILBERTH no banheiro, o qual aduziu que recebia dinheiro para embalar as drogas e que o corréu CARLOS MAGNO ajudava a embalar e a embarcar as drogas. Aduziu que continuando as investigações, pelo CNPJ, chegaram em outros endereços relativos a "Edu Tur" e chegaram ao dono, de nome Eduardo. Realizadas buscas e apreensão, conseguiram apreender balanças de precisão e mais cerca de 5kg de maconha no endereço da rua Rondon. Aduziu que o réu GILBERTH relatou que estava trabalhando no local há algumas semanas. Esclareceu que o referido réu morava no local, pois além de ter dito que ali morava, havia colchão. O réu CARLOS MAGNO, pelo que apuraram, também

usava o local para dormir. Esclareceu que apuraram que o referido Eduardo possuía três endereços onde houve o cumprimento de mandados de busca (Rua Rondon, Rua Rio Branco e Rua Helvetia). Parte das drogas ficavam no endereço diligenciado para serem distribuídas e movimentadas para um segundo ponto na Rua Rio Branco e depois para a Rua Helvetia. Aduziu que GILBERTH relatou que ganhava cerca de R\$ 500,00 para embalar as drogas e que CARLOS MAGNO ajudava a embarcar as drogas e auferia de R\$ 1.000,00 a R\$ 2.000,00 para cumprir essa função. Disse que CARLOS MAGNO não foi entrevistado na hora e no local porque desferiu um empurrão no depoente e saiu correndo.

A testemunha Genildo Fonseca Nascimento Filho disse que denúncias reiteradas apontavam que o local era depósito de drogas e distribuição para outros estados do país. No dia dos fatos se deslocaram ao local onde avistaram um ônibus em frente à empresa "Edu Tur", que distribuía e enviava mercadorias para o país. Mas no ônibus não havia nada, nenhuma mercadoria. Abordou os dois ocupantes do ônibus, onde não havia mercadorias. Neste momento, o réu CARLOS MAGNO abriu a porta do local, de onde saiu um cheiro forte de maconha. O réu cheirava maconha. Solicitou o celular dele e entrevistou os ocupantes do ônibus. Neste momento, o réu CARLOS MAGNO empurrou seu colega Andre e saiu correndo. Ato contínuo, chamou os ocupantes do ônibus para vistoriar e acompanhar o local, e abriu caixas, nas quais encontrou uma caixa com tijolos de maconha. Em continuação à vistoria, encontraram o corréu GILBERTH no banheiro escondido, o qual confessou que ganhava R\$ 500,00 para embalar as drogas e CARLOS MAGNO ganhava R\$ 1.000,00. Aduziu que eles disseram que as drogas eram de um indivíduo de nome Eduardo e, continuando as investigações, conseguiram encontrar o referido Eduardo, reconhecido por fotos pelos réus e apontado como dono das drogas, e, em diligências, apreenderam com Eduardo cerca de 5kg de maconha. Aduziu que GILBERTH disse que estava trabalhando no local há cerca de duas semanas. Reiterou que os ocupantes do ônibus disseram que seu contato na empresa era um indivíduo de nome Eduardo. Disse que pegou o documento e o celular do réu CARLOS MAGNO e que a roupa dele cheirava muito ruim (sic), odor forte de maconha. Aduziu que a conduta/função dos réus era embalar as drogas e levar ao ônibus. Esclareceu que na abordagem e nas investigações constatou que a função do réu GILBERTH era embalar as drogas dentro do local e a de CARLOS MAGNO era levar as drogas até o ônibus e acompanhava a distribuição. Aduziu que Gilberth foi vital nas investigações pois seu depoimento foi esclarecedor.

A testemunha Valdemir Soares Correa relatou que trabalha com ônibus de turismo e combinou com o sr. Eduardo para fazer o transporte de encomendas. Disse que parou o ônibus na frente da agência Edu Turismo e aguardou para combinar valores e prazo de entrega. Estava com seu filho e outro motorista. No dia dos fatos, quando estava mexendo em seu celular, foi abordado por policiais que perguntaram se tinham drogas, revistaram tudo e não acharam nada. Disse que a porta da agência estava aberta e o réu CARLOS MAGNO abriu a porta, momento em que foi abordado pelos policiais. Disse que quando os policiais abriram o porta malas de um carro aí no endereço, o réu CARLOS MAGNO saiu correndo. Logo depois um dos policiais voltou e chamou o depoente e o outro motorista para acompanharem a vistoria no local. Abriram uma caixa, onde havia drogas. Depois continuaram a varredura no local e encontraram o corréu GILBERTH no banheiro. Aduziu que na caixa aberta pelos policiais havia diversas barras de drogas. Aduziu que os policiais indagaram ao depoente se ele iria transportar aquelas drogas, ao que disse que não sabia o que iria carregar, pois o combinado era carregar mercadorias. Aduziu que já havia realizado transporte para a Edu Tur em outras 03 ou 04 oportunidades, e sempre viu o réu CARLOS MAGNO no local. Esclareceu que todas as vezes que foi contratado para transportar mercadorias, o contato foi feito por meio do sr. Eduardo. Disse que as caixas eram lacradas, então quando fazia os fretes não desconfiava que era ou se era produto ilícito.

Interrogado, o réu GILBERTH negou os fatos. Aduziu que nada tinha a ver com as drogas no local. Era usuário de drogas, tinha ciência pois já tinha visto drogas no

local. Disse que chegava mercadorias e drogas trazidas por um indivíduo de vulgo Maranhão e já tinha visto várias vezes drogas ali. Aduziu que era usuário de drogas e que laborava como diarista no local, recebendo dinheiro. Não morava no local, apenas fazia uns "bicos" ali (sic). Esclareceu que a sua função era carregar e descarregar caixas do local, e estava trabalhando ali há cerca de 03 semanas. Relatou que o corréu CARLOS MAGNO morava no local, e que ele fez um uma espécie de "compensado" (quarto). Aduziu que o indivíduo "Maranhão" ia ao local sempre de forma rápida, não conversava com ninguém, exceto com o CARLOS MAGNO, e ia embora. Ele dizia para o CARLOS MAGNO "é flagrante aí" (sic), e era muita droga, porque eram caixas.

Interrogado, o réu CARLOS MAGNO negou os fatos. Disse que no dia dos fatos os policiais foram atendidos pelo interrogando e eles já foram invadindo o local e o agredindo. Disse que aduziu que trabalhava na agência com passageiros do Maranhão e auferia R\$ 50,00/dia. Aduziu que não sabia se tinha drogas no local e que os policiais ficaram forçando o interrogando a falar se tinha drogas no local. Aduziu que estava drogado e por isso que fugiu, com medo de apanhar dos policiais. Relatou que laborava para um indivíduo de nome Eduardo e que estava no local há cerca de 15 dias. Aduziu que contratou o corréu GILBERTH para ajudar a carregar as mercadorias. Negou que morava no local. Relatou que quem tinha a chave do galpão era o sr Eduardo.

Pois bem.

O conjunto probatório revelou ser incontroversa a autoria delitiva do réu CARLOS MAGNO acerca do delito de associação para o tráfico, o mesmo não se podendo afirmar sobre o tráfico de drogas em relação a ambos os acusados e sobre a associação para o tráfico imputada ao réu GILBERTH.

Os policiais civis disseram que receberam informações no sentido de que em determinado local, onde funcionava uma empresa chamada "Edu Turismo", havia distribuição de drogas, que partia para os respectivos destinos disfarçadas de "encomendas".

Rumaram então para o local para investigar, ocasião em que avistaram um ônibus em frente ao local e realizaram campana.

Após alguns minutos de campana abordaram o ônibus, que era ocupado pelas testemunhas Marcos Antonio e Valdemir.

Em revista pessoal nas testemunhas, nada foi encontrado.

Ato contínuo, os policiais avistaram o local, que estava com a porta entreaberta e exalava forte odor de maconha, ocasião em que o réu CARLOS MAGNO terminou de abrir a porta e foi abordado, franqueando a entrada dos agentes no local.

Indagado sobre a existência de drogas no local, CARLOS MAGNO demonstrou nervosismo e, ao entregar se telefone e documentos, proferiu forte empurrão em um dos policiais e se evadiu do local.

Durante a varredura no local, os policiais chamaram as testemunhas Valdemir e Marcos Antonio para acompanharem a diligência e abriram algumas caixas, notadamente a que exalava odor de entorpecente.

Aberta a referida caixa, os policiais encontraram 27 tijolos de maconha, com peso aproximado de 28,6kg.

Continuando a varredura no local, os policiais encontraram o réu GILBERTH, escondido no banheiro, o qual, indagado, aduziu que ele e o corréu CARLOS MAGNO

recebiam a quantia de R\$ 500 reais de uma pessoa de nome Eduardo para embalar tais entorpecentes e que CARLOS MAGNO recebia mais R\$ 2.000,00 reais para embarcar junto com as substâncias nos ônibus e entregar aos seus destinos.

Se por um lado a palavra dos policiais merece credibilidade, é inegável que a versão dos réus não se mostrou totalmente inverossímil, dela exsurgindo alguns elementos plausíveis.

Nesse sentir é de se ressaltar que em relação ao crime de tráfico de drogas não há prova da prática de qualquer conduta praticada por qualquer dos réus que se subsuma ao verbos núcleos do tipo penal de tráfico de drogas.

A acusação, neste aspecto, não se desincumbiu de provar que os acusados guardavam e mantinham em depósito os entorpecentes, mormente quando os réus sequer possuíam domínio sobre o local, vez que não eram proprietários ou possuidores do imóvel em que as drogas foram encontradas e sequer guardavam ou possuíam as chaves do galpão/estabelecimento onde estavam as drogas.

Assim, sequer se pode dizer que possuíam aquelas mercadorias ilícitas e, por corolário, sequer poderiam manter, guardar ou manter em depósito algo que sequer possuem.

Deste modo, a prova se mostrou anêmica e duvidosa em relação ao crime de tráfico de drogas em relação a ambos os réus, sendo inviável um decreto condenatório nesse sentido.

Lado outro, no que se refere ao delito de associação para o tráfico, parcial razão assiste ao Ministério Público, apenas em relação ao réu CARLOS MAGNO.

Nesse sentir, a prova testemunhal o apontou como autor do delito, vez que restou comprovado nos autos que ele possuía a função de colocar as caixas de drogas embaladas por GILBERTH nos ônibus que vinham buscá-las, para despachar aos clientes que a encomendavam.

Lado outro, a testemunha Valdemir foi assertiva ao aduzir que já tinha realizado transporte para o dono do galpão (Sr. Eduardo) algumas vezes, pelo menos 04 vezes, e sempre via CARLOS MAGNO no estabelecimento, revelando vínculo estável e permanente deste réu com o tráfico.

Além disso, as testemunhas oculares Valdemir e Marcos Antonio foram assertivas ao aduzir que viram ambos os réus dentro do estabelecimento, que viram o réu CARLOS MAGNO se evadir correndo após empurrar o policial, e viram os policiais abrindo a caixa onde foram encontradas as drogas.

Nesse sentir, diante dos fatos de ter sido diversas vezes no local anteriormente, notadamente pela testemunha Valdemir, que "sempre" viu o acusado no estabelecimento nas vezes em que se dirigiu ao local para pegar as mercadorias para transportar - repise-se -, mais do que evidente se mostra o vínculo estável e permanente do réu CARLOS MAGNO com o tráfico.

O renomado doutrinador RENATO BRASILEIRO DE LIMA nos ensina que:

Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão "reiteradamente ou não", a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de u concurso eventual de agentes (CP, art. 29). (grifos nossos).

No mesmo sentido, o entendimento pacífico do C. STJ, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. (...). 2. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os réus, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação. 3. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a *societas sceleris* e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. 4. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado. 5. (...). 6. (...). 7. (...). (AgRg no AREsp 1916729/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

E mais:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre os pacientes e os integrantes da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho; na verdade, as instâncias de origem presumiram, com base apenas no local em que os réus foram presos em flagrante, que eles seriam integrantes do Comando Vermelho e, assim, proclamaram a condenação destes com base em meras conjecturas acerca de uma *societas sceleris*. 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. Ordem concedida, para absolver os pacientes pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e aplicá-la no patamar máximo de 2/3. (HC 596.389/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021). (grifos nossos).

No que tange ao réu GILBERTH, não há provas acerca da associação para o tráfico.

Referido acusado foi categórico em afirmar que estava laborando no local há apenas 02 ou 03 semanas e que sequer dormia no estabelecimento onde as drogas foram encontradas, de modo que inexistente qualquer conduta caracterizada por estabilidade ou permanência por parte do acusado

Não se olvida que as provas demonstram de forma candente e veemente que o réu GILBERTH laborava no local e auxiliava embalando caixas.

Todavia, a acusação não comprovou há quanto tempo referido réu GILBERTH vinha desempenhando referida atividade, de modo que não se desincumbiu de demonstrar as elementares estabilidade e permanência com o tráfico, a exemplo do demonstrado em relação ao corréu CARLOS MAGNO, que fora visto no local por diversas vezes pelos transportadores, notadamente pela testemunha Valdemir, demonstrando que este acusado possuía vínculo estável e permanente.

De mais a mais, anêmica a prova, necessário se faz observar o princípio do favor rei.

Assim, materialidade e autoria comprovadas apenas em relação ao crime de associação para o tráfico e apenas em relação ao réu CARLOS MAGNO, a condenação deste réu pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas é medida que se impõe. Passo à dosimetria das penas.

Réu CARLOS MAGNO DURANS RODRIGUES:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, e ao disposto no art. 42, caput, da Lei de Drogas, considerando os maus antecedentes (condenações definitivas perante a 9ª Vara Criminal, processo nº 0008307-56.2001.8.26.0050 - fls. 44 e F.A. com trânsito em julgado fls. 84; e perante a 27ª Vara Criminal, processo nº 0026724-47.2007.8.26.0050 - fls. 44 e F.A. com trânsito em julgado fls. 84/85) e a expressiva quantidade de drogas apreendida com o réu, fixo a pena base em 1/3 acima do piso legal, perfazendo 04 anos de reclusão e pagamento de 933 dias-multa. Na segunda fase, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação denexo causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida a ré teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece inalterada. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a considerar, torno o quantum definitivo.

Ausentes os requisitos legais, notadamente a quantidade de pena imposta e os maus antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou de conceder o sursis, posto que tais medidas não seriam socialmente recomendáveis.

Fixo o dia multa no valor mínimo, ante a ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da presente ação penal para: (a) CONDENAR CARLOS MAGNO DURANS RODRIGUES, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 04 anos de reclusão e pagamento de 933 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 35, caput, da Lei 11.343/2006; (b) ABSOLVER GILBERTH JOSÉ DA SILVA MENEZES, qualificado nos autos, das imputações de ter infringido os arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, o que faço com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e (c) ABSOLVER CARLOS MAGNO DURANS RODRIGUES da imputação de terem infringido o art. 33, caput, da Lei 11.346/2006, o que faço com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O réu CARLOS MAGNO iniciará o cumprimento da sua pena, seguindo os ditames legais, em regime semiaberto, em virtude da quantidade de pena imposta, da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), e da gravidade em concreto da conduta, nos termos do art. 33, § 2º, "b", c.c. súmulas 269 e 440 do C. STJ, todos interpretados a contrario sensu.

Quanto ao regime prisional, insta salientar que a detração consiste em mera operação aritmética (desconto do tempo de prisão provisória da pena aplicada), não possuindo, de per si, o condão de modificar o regime inicial sem se sopesar as circunstâncias e a gravidade em concreto do crime e as condições subjetivas dos acusados, que, ao serem apreciadas, revelaram não ser recomendável a fixação de regime mais brando que os ora fixados, porquanto os regimes prisionais se revelaram proporcionais e suficientes para a reparação e reprovação do crime.

Ademais, ainda que se utilizasse apenas o desconto do prazo de prisão provisória para fixar o regime prisional - hipótese rechaçada -, nenhum dos acusados não faria

jus à progressão, nos termos do art. 112, V da LEP (Lei 7.210/84).

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. O réu CARLOS MAGNO não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido presos durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704 proferido pelo STF. Recomende-se.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DO RÉU GILBERTH JOSÉ DA SILVA MENEZES.

Servindo a presente como ofício, determino a incineração do entorpecente e a destruição da balança de precisão apreendida nos autos, posto que utilizada para a pesagem de drogas. Quanto ao telefone celular, transcorridos 90 dias da data do trânsito em julgado sem que o legítimo proprietário comprove a propriedade, bem como não havendo interesse policial, promova-se a inutilização ou destruição do aparelho.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA